

1500352-26.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... vindo da Vila Nova Horizonte, local em que há tráfico de drogas.

Informalmente, o réu afirmou que comprou os entorpecentes, junto com amigos, para as festas de fim de ano. Acredita que o réu morava no Bairro do Cruzeiro. Sabia que o réu havia sido preso por tráfico.

Portanto, a prova colhida apenas demonstra que o réu transportava entorpecentes, não havendo prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500352-26.2021.8.26.0622 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500352-26.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2347517/2021 - Delegacia de Polícia de Itararé, 22079519 - Delegacia de Polícia de Itararé, 2255/21/409 - Delegacia de Polícia de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo da Silva Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de dezembro de 2021, à tarde, na Rua Heitor Pedroso de Mello, altura do número 1900, Santa Terezinha, cidade e comarca de Itararé, trazia consigo drogas, consistentes em 245,47g de maconha e 12,97g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão fls. 16/17, constatação provisória fls. 18/19).

Narra a denúncia (fls. 118-119):

“Segundo o apurado, GUSTAVO era conhecido do meio policial exatamente por promover o tráfico de drogas, ostentando condenação anterior por tal delito.

Na data em questão, guardas civis realizavam patrulhamento de rotina e viram o denunciado na garupa de uma moto Honda/CG, conduzida por Gabriel Rodrigues Guimarães Inácio.

Ao notarem a viatura, os ocupantes da motocicleta empreenderam fuga e houve perseguição, em meio a qual, na Rua Heitor Pedroso Melo, GUSTAVO atirou em um terreno aquilo que viria a se saber tratar-se das mencionadas drogas.

Os guardas conseguiram abordar os agentes e, realizada a competente revista pessoal, com Gabriel havia R\$ 10,00 e com Gustavo R\$ 280,00 e um aparelho celular. Depois, de volta àquele terreno, apreenderam um tijolo de maconha e três porções de cocaína.

Gustavo foi preso em flagrante, mas quanto a Gabriel não foram apurados indícios relevantes de que estivesse agindo em concurso com o primeiro.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, somadas à conduta concreta do denunciado, que tentou se desvencilhar do objeto, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes."

Preso em flagrante, o Réu foi apresentado em audiência de custódia, na qual foi decretada a prisão preventiva.

O réu foi notificado e citado (fls. 192-193).

Foi apresentada resposta à acusação por defensor constituído (fls. 145-150).

Foi recebida a denúncia em 07 de fevereiro de 2022 e designada a audiência de instrução e julgamento. (fls. 184-187).

Nesta assentada, foram ouvidas oito testemunhas, ao final, interrogado o réu.

Juntado o laudo pericial do celular do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia; e a Defesa postulou, inicialmente, o reconhecimento da ilicitude da apreensão das drogas, com consequente absolvição do réu, e subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 ou para o art. 33, §3º,

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

Preliminar - Prova Ilícita

De acordo com a Defesa, a busca pessoal realizado no réu, e consequente apreensão dos entorpecentes, se deu após atuação investigativa prévia da Guarda Municipal, o que extrapolaria a competência legal e constitucional atribuída pelas GCMS.

Nesse sentido, o réu narrou, em seu depoimento em juízo, que havia um Gol Prata de campana no local dos fatos, ocupado por um Guarda Civil, e que tal Guarda Civil repassou as informações à ROMU (Rondas Ostensivas Municipais). Em posse de tais informações, é que teria sido realizada sua abordagem.

A versão do réu, contudo, carece de substrato probatório. Não há qualquer prova em concreto de que, de fato, havia um Gol Prata no local, ou ainda que tal Gol Prata seria ocupado por um GCM, que acompanhou sua prisão em flagrante.

Pelo contrário, ambos os Guardas Municipais narram, em juízo e em solo policial, que o que levou a abordagem do réu foi sua mudança brusca de direção da motocicleta (na qual o réu estava na garupa) ao visualizar a viatura. Disseram também que viram o réu dispensando os entorpecentes. Tal conduta caracteriza a fundada suspeita necessária para busca pessoal (art. 240, §2º, do CPP), o que é facultado aos Guardas Municipais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente "rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas". Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 658682 SP 2021/0105328-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Diante disso, ademais, válida a prisão em flagrante do réu, uma vez que qualquer um do povo pode efetuar prisão em flagrante (art. 301 do CPP).

Ante o exposto, afasto a preliminar de ilicitude da prova.

Desclassificação - Cedente Eventual (art. 33, §3º, da Lei 11.343/06)

A materialidade do delito de tráfico de drogas não restou demonstrada para além de qualquer dúvida razoável, uma vez que não há prova concreta de que a droga apreendida se destinava à traficância.

Nesse sentido, a jurisprudência, consolidada pelo C. STJ e pelo E. STF, estabelece que compete à acusação demonstrar a traficância/comércio ilícito de entorpecentes, por se tratar de parte integrante do tipo subjetivo do tráfico de drogas (vide STF HC 107448, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, STJ. REsp 1769822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

No caso em tela, as provas colhidas em juízo demonstram que o réu foi preso transportando a quantia de 245,47g de maconha e 12,97g de cocaína, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de exibição e apreensão dos entorpecentes (fl. 16-17), laudo de constatação provisório (fl. 18-19), e exame toxicológico.

Nesse sentido, a testemunha Felipe, um dos GCMs responsáveis pela prisão do réu, narrou que sua equipe realizava o patrulhamento. O réu veio transitando na garupa de uma motocicleta. O motorista, ao perceber a viatura, mudou bruscamente de direção, em uma manobra indevida, o que levou ao seu acompanhamento. Na perseguição, o réu, o réu levantou a camiseta, jogando ao lado esquerdo, em um matagal, certos os objetos. Posteriormente, esses objetos foram localizados, constando-se que se trata de entorpecentes. O local da abordagem não é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, mas o réu estava vindo da Vila Nova Horizonte, local em que há tráfico de drogas. Informalmente, o réu afirmou que comprou os entorpecentes, junto com amigos, para as festas de fim de ano. Acredita que o réu morava no Bairro do Cruzeiro. Sabia que o réu havia sido preso por tráfico.

Portanto, a prova colhida apenas demonstra que o réu transportava entorpecentes, não havendo prova contundente acerca da destinação da droga apreendida. O réu não foi visto vendendo entorpecentes, nem foram com eles localizados petrechos típicos do tráfico de drogas (balanças, etc.)

Observo que as fotos localizadas no celular do réu, conforme laudo pericial de fls. 249-255, apesar de levantarem suspeita de traficância, não demonstram que a droga localizada com o réu naquele dia se destinava ao tráfico. É possível que o réu seja traficante. Contudo, tal fato por si só não estabelece a materialidade do crime em questão, pois não diz respeito especificamente qual a destinação da droga com ele localizada. Ademais, não se pode afastar a versão defensiva que tais fotos seriam decorrentes de grupos de usuários de maconha.

Por outro lado, a tese defensiva de que a droga se destinava ao consumo conjunto possui ressonância nos autos. Assim, mesmo que não havendo certeza absoluta quanto sua destinação, a desclassificação se impõe.

Inicialmente, observo que o réu manteve a mesma versão (de que havia comprado os entorpecentes para uma festa com amigos no fim de ano) ao longo de toda a persecução penal. Assim, conforme narrado pela própria testemunha Felipe, responsável pela prisão do réu, este, já no momento de sua prisão, afirmou que a droga era destinada a consumo conjunto.

Também em juízo o réu deu a mesma versão. Disse que comprou a droga com amigos para uma festa de natal (Chico, Deison, Vagner e Eliel). Ficou responsável pela compra da droga, porque já conhecia o ponto de venda e sabia que lá era mais barato. Foi a primeira vez que foi comprar drogas para rateio com esses amigos. Já fez o rateio, porém com outras pessoas. Recebeu dos amigos a quantia de R\$ 375,00, a qual inteirou para o montante de R\$ 500,00. Toda a droga ia ser consumida em uma festa, em uma casa alugada, no dia do natal. Ele, Chico e Eliel participaram do rateio da cocaína. Vagner e Chico contribuíram apenas para a compra da maconha. Na época, trabalhava com corte de eucalipto. A droga nunca impediu o trabalho. Nunca teve uma situação de descontrole mental.

Também a prova oral corrobora a versão do réu, não tendo sido detectadas contradições aptas a credibilidade dos depoimentos das testemunhas.

Nesse sentido, as testemunhas arroladas pela defesa, e ouvidas em juízo sob compromisso, narram que o réu havia adquirido os entorpecentes para que fosse

consumido de forma conjunta em uma festa de natal. Havia sido feita uma "inteira", sendo que cada qual havia contribuído com uma certa quantia em dinheiro para aquisição das drogas, havendo diferenças, pois nem todos participaram do rateio da cocaína.

Nesse sentido, a testemunha Deison narrou, sob compromisso, que conhece o Gustavo há 8-9 anos. Sabe que o réu foi preso no dia 21 de dezembro, sob acusação de tráfico. Havia feito uma "inteira" para fazer uma festinha. Contribuiu com 70 reais, apenas pela maconha. Não sabe quanto os demais pagaram, pois não estava incluído na cocaína. Participaram do rateio, além dele próprio, Gustavo, Chico, Eliel e Vagner. Um total de 5 (cinco) pessoas. Já usou anteriormente droga com Gustavo e com as demais testemunhas. A intenção era utilizar apenas no dia do natal. Por conta do narguilé, a quantidade de maconha necessária era maior. O narguilé era do Vagner. A festa de natal ia ser no "Beckinha". Já Gustavo tinha adquirido comes e bebes (carne, linguiça, pão de alho), depois iriam dividir. Para ele, Gustavo nunca vendeu Drogas.

A testemunha Francisco, ouvida sob compromisso, narrou que conhece o Gustavo há 12-13 anos. Foi feita "inteira" para uma festa. Participou do rateio tanto da maconha quanto da cocaína. Contribuiu com R \$125,00. Usava drogas quase toda semana com Gustavo. As drogas apreendidas seriam utilizadas apenas na festa do natal. Por conta do narguilé, era necessária uma quantidade maior de entorpecente. Gustavo comprou os comes e bebes para a festa. Todo mundo trabalhava e por isso, foi decidido que Gustavo iriam buscar as drogas. Ele próprio nunca foi comprar droga para rateio.

A testemunha Silvia, ouvida sob compromisso, narrou que é operadora de caixa na Verdum. Namora Gustavo desde agosto de 2019, tinha ciência que Gustavo era usuário de maconha. Gustavo lhe contou que iria fazer uma festa, e iria buscar droga para os amigos, por um rateio. Disse-lhe que quem iria participar do rateio era Gustavo, Vagner, Chico, Dieson e Eliel. Havia comprado outras coisas para festas. Gustavo não vende drogas. Costumava usar drogas com Chico e com o Vagner. Costumava usar com eles 2x a 3x na semanas Gustavo era usuário de maconha, usando diariamente. O réu trabalhava. Nunca presenciou uma situação de perturbação mental

A testemunha Vagner, ouvida sob compromisso, narrou que conhece o réu há 2 anos. Havia uma "inteira" e Gustavo ficou responsável de ir buscar as drogas. Contribuiu com 90 reais apenas pela maconha. Eram 5 pessoas no rateio. Usava maconha umas 2x na semana com Gustavo. Com os demais, usou apenas algumas vezes. As drogas apreendidas seriam utilizadas somente no dia do natal. Iam fumar no narguilé, o que exige uma maior quantidade. Ia dar umas 10 porções durante a noite. O narguilé é dele. Gustavo comprou os comes e bebes. E iria dividir em partes iguais. Gustavo se ofereceu para buscar drogas. Cada hora, era um que ia. Não era costume dele ir buscar as drogas. Toda a semana fumava maconha, de 1 ano para cá.

Portanto, a Defesa logrou criar fundada dúvida de que tais entorpecentes se destinavam ao consumo conjunto em uma dada ocasião festiva. Resta analisar se os requisitos do tipo previsto no art. 33, §3º, da Lei 11.343/06 encontram-se presentes. Tal norma prevê quatro requisitos: i) eventualidade (impossibilidade de oferta reiterada ou habitual); ii) ausência de intenção de lucro, ou seja, gratuidade na oferta; iii) oferta para pessoa do relacionamento do ofertante; iv) droga destinada ao consumo conjunto.

Tais requisitos encontram-se preenchidos no caso concreto.

Quanto a eventualidade, ao contrário do narrado pelo Ministério Público, restou demonstrada. Em nenhum momento as testemunhas narram que o réu Gustavo teria ofertado droga para consumo conjunto deles em outras oportunidades. É certo que todas, contudo, narram que consumiam junto com o réu entorpecentes. Não narram, porém, quem trazia ou ofertava os entorpecentes nessas outras oportunidades. Nem detalharam de quem seriam as drogas utilizadas nessas ocasiões. Também o réu, em seu interrogatório, foi enfático que comprou drogas para rateio apenas naquela oportunidade apenas, sendo que das demais vezes que foi no ponto de venda, foi comprar para consumo próprio. Portanto, não restou demonstrado que o réu oferecia, com habitualidade, drogas para o consumo conjunto de tal círculo de amizade. Também o fato de o réu ter participado de rateios em outras oportunidades, com outras

pessoas, não afasta a configuração do art. 33, §3º, da Lei 11.343/06, diante da necessidade de uma interpretação mais favorável ao réu.

Quanto à gratuidade, as testemunhas narram que as drogas foram divididas, ou seja, não haveria lucro por parte do réu Gustavo.

Quanto à oferta a pessoas do relacionamento do réu, todas as testemunhas narram que conhecem o réu há anos.

Por fim, quanto ao consumo conjunto, todas as testemunhas narram que a droga seria utilizada em um mesmo dia, na festa natal. É certo que a quantidade de droga apreendida levanta dúvidas se de fato todo o entorpecente seria destinado ao consumo em apenas uma oportunidade. Contudo, não compete a Defesa fazer prova cabal de que a droga não se destinava a traficância. Basta inculcar no julgador fundada dúvida de tal fato, o que foi feito.

Nesse sentido, a acusação não trouxe prova cabal de que a droga apreendida era manifestamente incompatível com o consumo pessoal.

Portanto, satisfeitos os requisitos há de se concluir que há fundada dúvida que a droga apreendida era destinada ao consumo conjunto do réu com as testemunhas, na festa de natal, de modo que necessário desclassificar a imputação para a infração ao artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06.

Consumação

Inviável adotar a tese defensiva de que o delito se deu na forma tentada.

Isso porque o núcleo do tipo do art. 33, §3º da Lei 11.343/06 tem como núcleo o verbo "oferecer". Portanto, trata-se crime unissubsistente (ou de conduta indivisível), que não comporta a forma tentada. Basta o mero oferecimento, sendo desnecessário o consumo efetivo da droga ou até mesmo a posse dos entorpecentes.

Individualização da Pena

De rigor, assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas o artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ao crime do art. 33, §3º, da Lei 11/343/06, são cominadas, em abstrato, as penas de detenção, de seis meses a 1 ano, e multa.

Para a dosimetria, parte-se, portanto, da pena mínima de seis meses de detenção e 700 dias multa (art. 49 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é mais exasperada, uma vez que o réu ofereceu entorpecentes para um conjunto de 4 amigos, afetando, portanto, a saúde de diversas pessoas.

No tocante às circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína) autoriza uma exasperação da pena base por seu alto potencial viciante. Por fim, também a quantidade de droga se mostra elevada para um cedente eventual (quase 250g de maconha). Ressalto que utilizo, por coerência às penas cominadas pelo legislador e em obediência ao princípio da proporcionalidade, o critério matemático de elevar a pena-base em um nono (pois nove são as circunstâncias judiciais aplicáveis aos crimes da Lei n. 11343/06) do resultado da subtração da pena máxima pela pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 0 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, incidem a agravante de reincidência, bem como a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas integralmente.

Assim, o réu é reincidente, conforme se extrai da certidão de fls. 238 (autos n. 0000080-10.2017.8.26.0279). Por outro lado confessou, espontaneamente, em audiência o delito, fazendo jus à atenuante do art. 61, III, "d", do Código Penal.

Portanto, nos termos do art. 67 do Código Penal, tal atenuante compensa, em regra, a agravante da reincidência (art. 62, I, "a", do Código Penal), uma vez que ambas circunstâncias expressam traços da personalidade, e portanto, devem ser tidas por predominantes (vide por todos STJ, AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Portanto, a pena-provisória é fixada, tal qual a pena-base, em 0 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição. Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 966 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime semiaberto.

Houve prisão cautelar no curso do processo. A segregação cautelar durou 0 ano(s), 4 mês(es) e 4 dia(s), de modo que resta cumprir uma pena privativa de liberdade correspondente a 0 ano(s), 3 mês(es) e 26 dia(s) de detenção. O tempo de prisão processual é superior ao lapso necessário para a primeira progressão de regime, o que permite, na forma do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena. Portanto, o regime inicial será o regime aberto.

Indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, pois o(a) acusado(a) é reincidente em crime doloso, o que exclui esse direito, na forma do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Indefiro a suspensão condicional da pena, pois o(a) acusado(a) é reincidente em crime doloso, o que exclui esse direito, na forma do art. 77, inciso I, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o delito praticado não tem vítima específica.

Da detida análise dos autos e à luz do art. 316 do Código de Processo Penal, extrai-se que deve ser modificada a situação processual do(a) acusado(a). Isso porque foi fixado o regime aberto, o que se mostra incompatível com a segregação cautelar.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para desclassificar a conduta imputada ao réu GUSTAVO DA SILVA SANTOS, já qualificado, para o crime previsto no art. 33, §3º, da Lei 11.343/06, e condená-lo, com incurso em tal artigo, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 0 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) de detenção em regime inicial aberto e ao pagamento de pena de multa no valor de 966 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para o cumprimento da penalidade estabelecida e oficie-se ao TRE, para cumprimento do disposto no inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03.

Determino a devolução do dinheiro apreendido, por não restar evidenciada sua vinculação com atividade ilícita. Expeça-se MLE.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

*

Itararé, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA